

1500920-77.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI
Comarca: São Pedro
Foro: Foro de São Pedro
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... de ser considerado equiparado a hediondo o delito de tráfico de drogas [AgRg no HC n. 750.428/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.].

Como os delitos de tráfico e resistência foram praticados mediante mais de uma ação em contextos fáticos diversos, as sanções aplicadas para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Pedro

Foro de São Pedro

2ª Vara

PRAÇA ADOLPHO BONIFÁCIO BRAGAIA, S/N, São Pedro - SP - cep 13520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500920-77.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500920-77.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONAS DONIZETI FERREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI

Vistos, etc.

JONAS DONIZETI FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 329, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, pois, segundo consta na denúncia, no dia 23 de junho de 2022, por volta das 14h20min., no campo de futebol, localizado na Rua Luís Carmezini, na cidade de Santa Maria da Serra, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 36 [trinta e seis] porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha" [massa líquida de 39,9g]; e 196 [cento e noventa e seis] porções de cocaína na forma solidificada, popularmente conhecida como "crack" [massa líquida de 25,6g], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado, opôs-se à execução de ato legal, mediante emprego de violência contra funcionários públicos Leonardo Luan Sola Evangelista e José Davi Barbosa Júnior, competentes para executá-lo.

A denúncia foi recebida em audiência [fls. 118/119].

O réu compareceu espontaneamente ao feito, requerendo habilitação de seu patrono e oferecendo resposta à acusação.

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual, após ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, interrogado-se o imputado ao final do ato.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, vale frisar que o feito se encontra regular, não havendo máculas a sanar, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito da contenda.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão [fls. 15], pelo auto de constatação de substância entorpecente [fls. 16/17], pela fotografia [fls. 18], pelo laudo de exame químico-toxicológico [fls. 55/57], e, por fim, pelos laudos periciais de fls. 81/83 e 154/169.

Quanto à autoria, de igual forma, emerge indubitosa da prova colacionada, recaindo certa sobre o incriminado, firmada que está na sua prisão flagrante, assim como na palavra coerente e convincente das testemunhas ouvidas durante a persecução penal. O imputado, na fase administrativa, permaneceu em silêncio.

Em pretório, disse que é usuário de maconha. Estava no ponto para comprar drogas. Avistou a presença dos policiais e tentou correr, mas não tentou pegar a arma de nenhum deles. Viu pessoas correndo. Tentou se evadir, mas não conseguiu. Não viu onde os policiais encontraram as drogas. Ainda não havia comprado estupefacientes. Não conhecia os armigeros. Disse que, quando foi segurado no chão pelo policial, acreditando que, quando estava tentando se debater, pode ter passado a impressão de ter tentado pegar a arma do armígero. Não viu quando encontraram ou onde encontraram as drogas. Falou para sua mãe que iria comprar drogas, antes de ir ao local. Costumava comprar em torno de 30 a 35 porções por vez, para não precisar ir mais de uma vez a pontos de venda de drogas por mês. Não sabe o nome da pessoa de quem adquiria as drogas. Estava na espera e não sabia quem iria vir lhe vender drogas. Por vezes há pessoas vendendo drogas, em outras vezes tem que esperar alguém vir vender. Asseverou que, quando chegou, já estavam perseguindo algumas pessoas. Possuíam em torno de R\$ 100,00 a R\$ 150,00 em dinheiro. O local é um campo de futebol.

Entretanto, as teses exculpatórias do imputado não resistem quando confrontadas com o restante da prova amealhada ao processo, estas, aliás, altamente incriminatórias, aptas a prolação de édito condenatório. Senão vejamos.

As testemunhas Leonardo Luan Sola Evangelista e José Davi Barbosa Júnior, nas duas fases da ausculta, afirmaram que estavam realizando patrulhamento de rotina. Ao chegarem no local dos fatos, onde existe um campo de futebol, lugar onde ocorre o ilícito comércio de entorpecentes, avistaram o acusado e uma mulher. Esclareceram que, ao perceberem a guarnição, a jovem evadiu-se correndo do local. Deteram o imputado que ofereceu resistência, tentando se apossar do armamento dos armigeros, forçando a retirada do coldre. Afirmaram que foi necessário a utilização de força moderada e algemas para contê-lo. Ao realizarem revista pessoal, encontraram uma pochete de cor preta e azul, contendo em seu interior 196 [cento e noventa e seis] pedras amarelas, aparentando ser crack; 36 [trinta e seis] porções de erva verde, semelhantes a maconha; R\$12,00 [doze reais] em espécie e 01 [um] aparelho celular. Asseveraram que o acusado confessou que tratava-se de drogas destinadas ao comércio espúrio. Declararam que conduziram o imputado para a Delegacia de Polícia, para as tomarem as medidas cabíveis. Em juízo, afirmaram que no local dos fatos há um campo de futebol do município e que é conhecido como ponto de venda de drogas. Asseveraram que o imputado resistiu, investindo contra um dos policiais. Disseram que o acusado tentou se apossar da arma de um dos armigeros. Havia denúncias de que o increpado alicia menores para a prática da chatinagem. O local é um campo municipal da cidade, mas se encontra em situação de abandono. A arma do PM David que o réu tentou se apossar, chegando a colocar a mão na arma. A pochete apreendida estava na cintura do imputado. Também em pretório, a testemunha José, afirmou que o palco dos acontecimentos é ao lado de uma escola de educação infantil e é um campo de futebol que está abandonado, havendo prática de esportes mas de maneira informal. Encontraram a menor Dominique e o inculcado no local. Conhecia só de nome

o increpado por ter sido encontrada uma maquininha em nome do réu em outra apreensão. O imputado tentou sacar sua arma, não conseguindo por estar travada. Houve resistência do acusado. Havia várias porções de crack e de maconha com o inculpatado. Novamente asseriu que realizaram abordagem em outra oportunidade, mas sem conseguir prender ninguém. Naquela oportunidade encontraram drogas e anotações concernentes ao tráfico e uma maquininha, que, quando ligada, aparecia o nome do inculpatado.

Ainda no ponto, calha destacar, que o fato de ser agente de segurança pública não retira a credibilidade das informações trazidas pela testemunha. A condição funcional da testemunha não é causa de impedimento para ser ouvida como tal.

Ademais, não há qualquer indício de que tenham motivos para imputar graciosamente os fatos ao réu. Portanto, seus relatos são aptos à construção do convencimento e encontram-se em consonância com o restante das provas amealhadas aos autos.

Nesse sentido. E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROVA. Depoimento policial Valor Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas. Análise que se faz em cada caso concreto. O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra. Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal. Recurso improvido neste aspecto" (TJSP Apelação Criminal nº 993.08.043553-7 São Paulo 16ª Câmara de Direito Criminal Relator Newton Neves 09.09.2008 v.u.).

Na mesma senda, C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUADOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP, e ART. 42 da Lei n. 11.343/2006, e ART. 44, CP. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

II - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em qualquer outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).

III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

IV - Afastar a condenação com base na nulidade da instrução, em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feitas pelo eg. Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

V - Repiso, que seria necessário aprofundado reexame do conjunto fático probatório a análise da tese de que o paciente faria jus a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, constante do do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo inviável sua análise em razão dos limites impostos à via mandamental.

VI - Consoante ficou assentado na decisão agravada, o quantum de pena aplicado (6 anos de reclusão), o regime poderia, em princípio, ser o semiaberto. Todavia, não se pode olvidar a existência de circunstâncias desfavoráveis que foram consideradas na dosimetria da pena, na terceira fase, para afastar a causa especial de redução de pena. Assim, inviável a fixação do regime intermediário (semiaberto) unicamente

em razão do montante de pena imposto ao paciente, ex vi dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006.

VII - Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reprimenda encontra-se estabelecida acima do patamar prevista para o deferimento da benesse (6 anos de reclusão), nos termos do art. 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (original sem grifo)

Nessa esteira, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:

[...] o valor do depoimento testemunhal de servidores público especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

Portanto, ainda que o réu tenha negado a prática dos crimes a ele imputados, sua versão encontra-se completamente isolada das demais provas amealhadas aos autos. Verifica-se dos elementos de convencimento corporificados aos autos que os armígeros estavam realizando patrulhamento ostensivo de rotina quando, no palco dos acontecimentos, local conhecido como onde ocorre a chantinagem, visualizaram o imputado e um terceiro. Os agentes do estado conseguiram deter o acusado, este que tentara se evadir ao ver a guarnição. Ao abordar o inculcado, este passou a oferecer resistência, tentando, no ato, apossar-se da arma de fogo de um dos policiais. Realizada busca pessoal, com o inculcado encontraram as drogas apreendidas e dinheiro. Os agentes do estado relataram, ainda, que conheciam o acusado de outras ações que realizaram e de denúncia apócrifa, inclusive tendo apreendido uma máquina leitora de cartões bancários que, ligada, apresentava o nome do acusado como sendo seu proprietário.

E, enquanto os relatos das testemunhas presenciais dos fatos foram firmes, livres de contradição e com riqueza de detalhes, os relatos do inculcado, por sua vez, foram genéricos, sem explicações detalhadas, e sem qualquer lastro probatório nos autos que pudesse, ao menos, instaurar alguma dúvida.

Ainda, vale destacar que a Cidade onde ocorrera a prisão do implicado é pequena, naturalmente todos se conhecendo. Logo, era fácil ao inculcado arrolar testemunhas que pudessem corroborar seus relatos, o que não fez.

Outra situação que chama atenção e corrobora a tese acusatória é o fato de os estupefacientes terem sido encontrado na posse do increpado, o que rechaça a possibilidade de as drogas serem de terceira pessoa. Além disso, o palco dos acontecimentos, conhecido como ponto de venda de drogas, a circunstância de os armígeros já terem encontrado bens em posse de traficantes que pertenciam ao acusado - uma "maquininha de cartão" - , o dinheiro trocado e em espécie encontrado com o réu e a quantidade e natureza variada das drogas que ele portava são fatores que indicam também a destinação delas ao comércio espúrio [artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06].

E a tese de flagrante forjado não veio corroborada sequer por indícios carregados aos autos, ônus da prova que competia à Defesa [artigo 156 do CPP]. Além disso, reitera-se, não é crível crer que agentes do estado, andem portando drogas para incriminar graciosamente cidadãos.

Também não convence a versão do acusado de que esbarrou na arma do policial que realizava sua prisão. Novamente, nenhuma prova trouxe aos autos de sua versão exculpatória.

Além disso, as máximas da experiência indicam que Policiais Militares costumam entender como situação vexatória o fato de alguém ter conseguido ou, como no caso em liça, chegando próximo de conseguir se apossar de sua arma de fogo ou outro equipamento, situação que confere ainda mais credibilidade aos seus relatos.

Ante o exposto, tem-se que os elementos de prova colhidos nos autos são por demais contundentes quanto à autoria e materialidade dos fatos, não sobejando dúvidas de que o inculcado praticou o crime de tráfico de drogas [artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06] delito, aliás, equiparado a hediondo [artigo 2º da Lei nº 8.072/90], bem como opôs-se a execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça contra

servidor público que estava no exercício de suas funções, subsumindo-se sua conduta, dessa forma, também à figura típica do artigo 329 do CP.

Cabe remarcar que a condenação pelo tráfico, tal como composto o tipo penal com inúmeras condutas não reclama a identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a prova da efetiva ocorrência do ato de mercancia.

Deveras, "é desnecessária a comprovação de qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento quanto à incidência do art. 12, da Lei nº 6.368/76 pode decorrer do conjunto indiciário existente nos autos" (TJSP, Rev nº 261.898-3/2, rel. Egydio de Carvalho; no mesmo sentido, TJDF, AC 9.073, rel. Hermenegildo Gonçalves, RT 747/647, 745/633, 740/634, 739/639, 594/393, "apud" Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7ª edição, pág. 3.132).

Na realidade, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo específico. Este "aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita" [VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13ª edição, págs. 150/151, grifei]. O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização [STF, HC nº 69.806, rel. Min. Celso de Mello; STJ, RESp nº 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer].

De rigor, pois, a condenação.

O delito fora praticado, segundo se infere da prova jungida, nas imediações de sede de atividades recreativas e esportivas - um campo de futebol - imóvel pertencente ao Município. Destarte, aplica-se ao caso em liça a majorante do artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, C. STJ:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CONCLUSÃO DE QUE OS PACIENTES DEDICAVAM-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N.º 11.343/06. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE SEDE DE ATIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS, BEM COMO DE RODOVIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MERCANCIA NOS REFERIDOS LOCAIS. DESNECESSIDADE. PROXIMIDADE. SUFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Concluído pelas instâncias de origem, com arrimo nos fatos da causa, que os pacientes dedicavam-se às atividades criminosas, não incide a causa especial de diminuição de pena, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Para concluir em sentido diverso, há necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

2. Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. Na espécie, os pacientes foram flagrados praticando condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 nas imediações de "praça pública com quadras de esportes, onde é comum a prática de atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas", destacando, ainda, que "a locação do apartamento deu-se, estrategicamente, nas proximidades da rodoviária local, para facilitar a guarda dos estupefacientes", restando plenamente justificada a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

submete-se à regência do art. 44 do Código Penal, segundo o qual só faz jus ao benefício legal o condenado a pena inferior a 4 anos. Na espécie, tendo a reprimenda final alcançado 5 anos e 10 meses de reclusão, não é possível a pretendida substituição.

4. Embora a reprimenda final seja inferior a 8 anos, escoreita a eleição do regime inicial fechado, porquanto as circunstâncias do caso em testilha - apreensão de significativa quantidade de drogas de alto potencial lesivo (843 g de cocaína), em local próximo a sede de atividades culturais, recreativas e esportivas, bem como de rodoviária - demonstram que regime inicial mais brando não seria suficiente para a reprovação e a prevenção do delito em comento. Não há falar, pois, em constrangimento ilegal.

5. Habeas corpus denegado. (HC n. 416.787/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017.)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO. NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PRETÓRIO EXCELSO NO BOJO DO HC 127.900/AM. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. ACUSADO INTERROGADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA PRETÉRITA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. QUANTUM DE INCIDÊNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. ILEGALIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA. 3. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N.º 11.343/06. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAL SEDE DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS. COMPROVAÇÃO DE MERCANCIA NO REFERIDO LOCAL. DESNECESSIDADE. PROXIMIDADE. SUFICIÊNCIA. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. 5. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DELITO NÃO HEDIONDO. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC Nº 118.533/MS. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO DA QUINTA E SEXTA TURMAS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 512/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 6. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 127.900/AM, deu nova conformidade à norma contida no art. 400 do CPP (com redação dada pela Lei n. 11.719/08), à luz do sistema constitucional acusatório e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. O interrogatório passa a ser sempre o último ato da instrução, mesmo nos procedimentos regidos por lei especial, caindo por terra a solução de antinomias com arrimo no princípio da especialidade.

Ressalvou-se, contudo, a incidência da nova compreensão aos processos nos quais a instrução não tenha se encerrado até a publicação da ata daquele julgamento (10.03.2016). In casu, o paciente foi sentenciado em 3.8.2015, afastando-se, pois, qualquer pretensão anulatória.

2. O estabelecimento do redutor na fração de 1/6 não se mostrou, de modo flagrante, desarrazoado, diante da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida em poder do paciente - 91 porções de cocaína -, a atrair a incidência do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. Motivada de maneira concreta a fixação do quantum de aplicação do referido benefício, não há falar em ilegalidade.

3. Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. Na espécie, o paciente foi flagrado praticando condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 nas imediações de local sede de atividades recreativas e esportivas, restando plenamente justificada a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos submete-se à regência do art. 44 do Código Penal, segundo o qual só faz jus ao benefício legal o condenado a pena inferior a 4 anos. Na espécie, tendo a reprimenda final alcançado 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, não é possível a

pretendida substituição.

5. Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto. Outrossim, de acordo com o entendimento recentemente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC n.º 118.533/MS, julgado em 23.6.2016), "o crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda". Mudança de posicionamento quanto ao tema por parte da Quinta e Sexta Turmas desta Corte Superior, que culminou na revisão do entendimento anteriormente consolidado, pela Terceira Seção, e no cancelamento do enunciado n.º 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. Fixada a pena-base no mínimo legal, bem como aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, sendo a reprimenda final de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, é possível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

6. Habeas corpus parcialmente concedido a fim de fixar o regime inicial semiaberto. (HC n. 403.550/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 28/8/2017.)

Tendo em vista que a prova oral aponta que o local, malgrado utilizado para atividades de lazer e esportivas, estava sem receber os cuidados necessários pelo Proprietário do imóvel, o que, certamente, diminui consideravelmente sua utilização, por via de consequência, o número de pessoas expostas ao comércio espúrio, na terceira fase do processo dosimétrico, as incoativas serão elevadas em 1/6.

A inculpada conta com 30 anos de idade, é primária, não registra antecedentes, nem mesmo quando ainda inimputável, tampouco há nos autos provas seguras de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, Dessa forma, aplicável ao caso em testilha a minorante do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual, na última fase da individualização das incoativas, tendo em vista a natureza variada e, principalmente, a quantidade de drogas apreendidas, as incoativas serão reduzidas em 1/6.

Como a natureza e a quantidade das substâncias serão utilizadas na terceira fase da individualização das penas, em observância ao princípio que veda o bis in idem, a circunstância não será considerada na primeira fase da fixação das reprimendas. Em virtude da aplicação da benesse, seguindo o entendimento jurisprudencial do C. STJ, deixa de ser considerado equiparado a hediondo o delito de tráfico de drogas [AgRg no HC n. 750.428/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.].

Como os delitos de tráfico e resistência foram praticados mediante mais de uma ação em contextos fáticos diversos, as sanções aplicadas para cada um dos crimes devem ser ao final do processo dosimétrico somadas, nos termos do artigo 69 do CP.

Diante de todo o exposto, a absolvição é meta impossível de ser alcançada quanto ao delito em questão, inclusive por não haver nos autos qualquer causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, sendo totalmente imputável.

Passo a dosar as penas

Crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11. 343/06

1ª fase – circunstâncias judiciais [artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei nº 11.343/06]

A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta, não excede o ordinário.

O acusado não registra antecedentes.

O acusado é usuário de entorpecentes. Portanto, além de um péssimo exemplo para os demais integrantes da sociedade, contribui diretamente para a prática de outros delitos, inclusive equiparados a hediondo, contribuindo diretamente com a máquina malévola do crime organizado que coloca em risco a segurança pública e a paz social, colocando em risco todos os integrantes da sociedade.

Não vieram aos autos elementos acerca da personalidade do agente, do que se

depreende que seja normal.

Os motivos do crime são inerentes à espécie, lucro fácil às expensas da saúde pública.

As circunstâncias do delito desbordaram da previsão típica, tendo em vista que o increpado estava praticando a chatinagem em plena luz do dia e em local público, demonstrando ousadia e destemor.

As consequências do fato não destoaram das normais ao ilícito.

Não há comportamento da vítima a ser considerado, pois se trata de crime que atinge toda a coletividade.

Pelo conjunto desses vetores, fixo a pena-base em 6 [sies] anos de reclusão e 600 [seiscentos] dias-multa.

2ª e 3ª Fases – circunstâncias legais

Nos termos da fundamentação alhures, por aplicação do artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, elevo em 1/6 as incoativas, estabelecendo-as em 7 [sete] anos de reclusão e 700 [setecentos] dias-multa.

Também com base no exposto adrede, em virtude da incidência do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo as incoativas em 1/6, restando as penas definitivadas em 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão, bem como 584 [quinhentos e oitenta e quatro] dias-multa.

Quanto à razão unitária de cada dia-multa, tendo em vista a condição econômica do implicado, fixo-a em 1/30 [um trigésimo] do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Estabeleço como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, em observância ao que preceitua o artigo 33, do CP e o artigo 387, § 2º, do CPP, considerando as operadoras do artigo 59 do CP e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, analisadas na primeira fase da individualização da pena, e em razão da quantidade e variedade de estupefacientes encontrados em poder do inculpatado, um deles, aliás, de elevado poder viciante e destrutivo – crack –, mostrando ser o regime estabelecido o mais adequado às peculiaridades do caso em liça. Ainda, o fato de ter sido o delito perpetrado em local destinado a atividades desportivas, em plena luz do dia e em local público também são circunstâncias que indicam a necessidade do regime estabelecido.

A fixação do regime inicial de pena deve observar os critérios da natureza, quantidade da pena aplicada, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que também se aplica ao crime de tráfico [cf. STF – HC n. 111840, rel. Min. Dias Toffoli]. Segundo leciona Cezar Roberto Bittencourt, “quando aqueles três fatores (art. 33, caput, combinado com o seu § 2º e alíneas) não determinarem a obrigatoriedade de certo regime, então os elementos do art. 59 é que orientarão qual o regime que deverá ser aplicado, como o mais adequado (necessário e suficiente) para aquele caso concreto e para aquele apenado (art. 33, § 3º, do CP)” [Tratado de Direito Penal. Parte Geral. 12 ed. São Paulo: Saraiva 2008, p. 450]. Ademais, os dados fáticos da conduta delitiva, quando demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena [cf. HC. n. 279.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC n. 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 19/11/2013; HC n. 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/11/2013; HC n. 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012]

Incabível a aplicação das benesses dos artigos 44 ou 77 do CP, seja pelo quantitativo punitivo aplicado seja pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis e mencionadas alhures quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Crime do artigo 329 do CP

1ª fase – circunstâncias judiciais

A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta, não excede o ordinário.

O acusado não registra antecedentes.

O acusado é usuário de entorpecentes. Portanto, além de um péssimo exemplo para os demais integrantes da sociedade, contribui diretamente para a prática de outros delitos, inclusive equiparados a hediondo, contribuindo diretamente com a máquina

malévola do crime organizado que coloca em risco a segurança pública e a paz social, colocando em risco todos os integrantes da sociedade.

Não vieram aos autos elementos acerca da personalidade do agente, do que se depreende que seja normal.

Os motivos do crime são inerentes à espécie.

As circunstâncias do delito desbordaram da previsão típica, haja vista que o inculcado resistiu mediante emprego de violência. Ainda, tentou apossar-se do armamento de um dos armígeros.

As consequências do crime não destoaram das normais ao ilícito.

Não consta tivesse a vítima contribuído para o delito.

Pelo conjunto desses vetores, fixo a pena-base em 5 [cinco] meses de detenção, incoativa que vai definitivada, porquanto não há circunstâncias legais a considerar.

Estabeleço como regime inicial de cumprimento de pena o ABERTO, em observância ao que preceitua o artigo 33, §2º e § 3º, do CP e artigo 387, § 2º, do CPP, considerando as operadores do artigo 59 do CP, analisadas na primeira fase da individualização da pena, mostrando-se o regime adequado e proporcional às circunstâncias do caso em liça.

Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito [artigo 44 do CP], tampouco de suspensão da execução da pena privativa de liberdade [artigo 77 do CP], ex vi do 69, § 1º, do CP. Ainda, a execução imediata da pena no regime estabelecido é mais benéfica ao inculcado.

As penas dos delitos, conforme já fundamentado alhures, deve ser somada, conforme determina o artigo 69 do CP.

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial acusatória, razão pela qual CONDENO JONAS DONIZETI FERREIRA à pena de reclusão, pelo período de 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses, em regime inicial FECHADO, e 584 [quinhentos e oitenta e quatro] dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato e, ainda, à pena de detenção, pelo período de 5 [cinco] meses, em regime inicial ABERTO, por incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 e artigo 329, do Código Penal, ambos na forma do artigo 69 do CP.

Indefiro o direito de o réu aguardar o trânsito em julgado da decisão em liberdade, porque persistem os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à segregação cautelar, agora mantida com base em um juízo de certeza da culpa. Além disso, o sentenciado portava para fins de venda drogas de elevado poder viciante e destrutivo e em quantidade relevante, em local destinado a atividades esportivas e de recreação, em plena luz do dia e em local público, o que demonstra a sua periculosidade e gravidade de sua ação, justificando-se a segregação cautelar como forma de manutenção da ordem pública e da paz social.

Custas pelo acusado.

Expeça-se o PEC provisório, adequando-se ao regime fixado.

Recomendo o condenado à unidade prisional em que se encontra.

Após o trânsito em julgado da sentença, se mantida a condenação, procedam-se às anotações de estilo, com o lançamento do nome do réu no rol de culpados, formação do PEC definitivo e posterior remessa à VEC, oficiando-se ao TRE.

Destruam-se as substâncias entorpecentes, nos termos do artigo 52-A e artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06.

Declaro o perdimento dos valores e bens apreendidos em posse do acusado, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Carta da República.

P.R.I.

São Pedro, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA